

1500088-36.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... que ostenta condenação anterior e irrecorrível por tráfico de droga (autos nº 0050162-15.2007.8.26.0564, da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 21/10/2011. Pena extinta em 22/06/2015, cf. certidão de distribuição criminal de págs. 48/50 e F.A de págs. 51/61).

As desfavoráveis condições subjetivas do acusado não podem ser olvidadas nesta etapa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500088-36.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-36.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007198/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22343684 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 132/22/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2007198 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIVALDO SOUSA DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

NIVALDO SOUSA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 04h30min, na Rua Evandro Caiafa Esquível, nº 67, bairro dos Alvarengas, nesta Comarca de São

Bernardo do Campo, tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, bens de valor econômico de propriedade de Gabriel Ferreira Araújo, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, na madrugada do dia 09 de janeiro de 2022, o acusado caminhava pela Rua Evandro Caiafa Esquivel, quando avistou o automóvel Fiat/Fiorino, de placas EVH-3578, estacionado defronte ao imóvel de numeral 67, e decidiu subtrair bens de seu interior.

Para tanto, o acusado quebrou o vidro da janela do motorista e tentou forçar a porta para abri-la.

Ocorre que a vítima estava na sala de sua residência e escutou o barulho provocado pelo acusado, razão pela qual foi à porta do imóvel ver o que estava acontecendo. Gabriel avistou o acusado mexendo na porta do carro e indagou o que ele estava fazendo, oportunidade em que NIVALDO largou seus chinelos e um alicate que trazia consigo e saiu correndo em fuga.

Durante a fuga, o acusado tropeçou e caiu. Levantou-se e continuou a correr, instante em que foi avistado por uma viatura da Polícia Militar que efetuava patrulhamento de rotina pelas imediações.

O acusado foi detido e indagado acerca do motivo da fuga.

Diante do silêncio do réu, os policiais voltaram ao local em que o acusado estava, onde encontraram os chinelos e o alicate utilizado para abrir o veículo, bem como constataram que o vidro do veículo pertencente à vítima havia sido quebrado, oportunidade em que o acusado confessou que tentara subtrair bens de seu interior. Nestas circunstâncias, ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

O furto somente não se consumou em razão da rápida intervenção da vítima e da eficaz atuação da Polícia Militar, surpreendido, o réu, durante a prática delitiva. Acompanhada por inquérito policial às págs.06/98, a denúncia foi recebida às págs.106/110. Regularmente citado (pág.124), o réu apresentou resposta à acusação (pág.127). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.129/130), em instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Daniel Lima da Silva.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, com elevação da reprimenda e fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena; ao passo que a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares da tentativa do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito está demonstrada no auto de exibição e apreensão às a págs.14/15 e nos laudos periciais de págs. 112/113 (alicate) e 133/135 (veículo).

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal o acusado confessou a prática do delito nos termos da denúncia.

Em Juízo, mantendo a versão anterior, declarou que pretendia subtrair objetos de valor do interior do veículo Fiat/Fiorino para comprar crack. Estava sob efeito da droga e quebrou o vidro da janela do carro com um soco, usado a própria mão. Neste momento, a vítima chamou a sua atenção, gritando. Diante da reação do ofendido, fugiu do local correndo. A via é uma descida. Tropeçou, caiu, levantou-se e ainda buscou fuga dos componentes de viatura policial que lhe deram ordem de parada. Foi detido.

O alicate e os chinelos localizados próximos do carro da vítima eram de sua propriedade.

O acusado confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada,

que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem corroborada, sob o crivo do contraditório, nas declarações da vítima Gabriel Ferreira Araujo, que narrou os lances do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, espancando qualquer dúvida acerca da autoria:

Era madrugada. A rua estava deserta e silenciosa. Assistia algo na televisão, na sala de casa, quando ouviu barulho de algo quebrando. Saiu no terraço e visualizou o agente quebrando o vidro da janela de seu veículo Fiat/Fiorino, estacionado do outro lado da rua. Gritou, chamando a atenção do furtador, que saiu correndo. Retornou ao interior da casa para chamar seus parentes e, ao sair, constatou que policiais militares tinham efetuado a abordagem do acusado, de pronto reconhecido pela fisionomia e pela vestimenta.

O réu pediu-lhe desculpa e disse que pretendia subtrair o aparelho de som do interior de seu veículo.

É manifesta a relevância probatória da palavra da vítima no delito de furto, praticado a clandestinidade, pois não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido (RJDTACRIM VOLUME 18 - ABRIL/JUNHO 1993 - PÁGINA: 194 - RELATOR:- ORLANDO BASTOS).

Não se olvida que, em Juízo, a vítima apontou o acusado, que ostentava a placa nº 03, como o possível autor do fato, afirmando que a ausência de certeza decorreu apenas do lapso temporal entre o fato e a sua oitiva em Juízo.

Tal circunstância é comum, diante do nervosismo que acomete as vítimas de crimes patrimoniais e do tempo decorrido entre o fato e a oitiva em Juízo. Não obstante, Gabriel foi firme ao apontar que, na data do crime, não teve dúvida de que o indivíduo preso pelos milicianos foi o autor da conduta criminoso. O positivo reconhecimento ocorreu com base na fisionomia e vestimentas do réu, que confessou aos policiais, no local da abordagem, a prática do delito.

As declarações da vítima foram corroboradas no depoimento do policial militar Marcelo Pereira Salapata, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na data do fato e espancou qualquer dúvida acerca da autoria:

Realizava patrulhamento de rotina quando avistou o acusado correndo pela via. Era madrugada, por volta de 04h00. Diante da atitude suspeita, deu ordem de parada. O acusado não a obedeceu e fugiu, mas logo foi detido.

Em seguida, moradores aproximaram-se para noticiar a tentativa de furto praticada pelo réu. O carro da vítima estava estacionado aproximadamente trinta e cinco metros do local da abordagem. Constaram que o acusado tinha quebrado o vidro da janela do automóvel.

Inquirido, o réu confessou a prática da tentativa de furto de objetos de valor do interior do veículo da vítima.

Próximo do carro foram apreendidos par de chinelo e alicate do acusado, que assumiu a propriedade.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de

investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

Ao cabo da instrução, a qualificadora do rompimento de obstáculo ficou cabalmente comprovada.

O perito atestou no laudo pericial juntado às págs.155/157 que o vidro da janela anterior do flanco esquerdo do veículo apresentava danos orientados de fora para dentro, produzidos por instrumento à guisa de percussão, ou de função similar, notando-se a presença de quatro pontos de impacto, com fraturas radiais e concêntricas (pág. 156).

Repita-se que o acusado admitiu que pretendia subtrair bens de valor do interior do carro. Trocaria o produto do crime por droga.

O crime não ultrapassou a esfera da tentativa. O acusado foi surpreendido pela vítima enquanto quebrava o vidro da janela do veículo. Assustado, correu. Somente foi identificado como autor do crime porque policiais militares causalmente realizavam patrulhamento no local e suspeitaram da conduta de Nivaldo, que corria pela rua deserta, de madrugada, e não obedecera à ordem de parada. Dessa forma, por circunstância alheia à vontade do réu, não houve efetiva inversão da detenção em posse.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no §1º, do artigo 155 do Código Penal.

O intuito da previsão é apenar mais severamente aquele que ataca o patrimônio desguarnecido, pois a vítima e populares repousam. Os bens estão mais vulneráveis à incursão do agente porque as pessoas estão menos atentas.

No tocante ao horário de aplicação do repouso noturno, o Superior Tribunal de Justiça entende que este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e desperta para a vida cotidiana. Sendo assim, não há um horário prefixado. Atenta-se às características intrínsecas da vida cotidiana da localidade.

Na hipótese dos autos, o delito ocorreu por volta de 04h30min. Não havia movimento de pessoas na rua e imediações.

A ação somente foi descoberta porque a vítima estava acordada no interior de sua residência e ouviu o barulho causado pelo rompimento do vidro do veículo. Incide a majorante.

Como anota Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado, 18ª edição, Editora RT, p. 967):

“A causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores em seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima que está em casa dormindo quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido objetivo da lei”.

Quanto à aplicação da causa de aumento do furto noturno na hipótese de furto qualificado, recente entendimento do C. STJ reforça sua procedência:

“A causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP que se refere à prática do crime durante o repouso noturno é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§4º) do delito de furto. Isso porque esse entendimento está em consonância, mutatis mutandis, com a posição firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.193.194-MG, no qual se afigurou possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), máxime se presentes os requisitos.

Dessarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se aplicar o § 2º do art. 155 do CP e deixar de impor o §1º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no §4º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o §1º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico. Cabe registrar que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma do STJ segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput do art. 155). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425-RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto. Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2º), também não se considera essa ordem para imposição da causa de aumento (§ 1º)" (HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014).

Entendimento diverso implicaria a não admissão do furto privilegiado às hipóteses qualificadas do referido delito, tendo em vista que a previsão de dito benefício também se encontra em parágrafo anterior. Não é este, todavia, o direcionamento dos Tribunais Superiores.

No mesmo sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado, 18ª edição, Editora RT, p. 964/965): "Em redor do tipo básico (caput), giram várias circunstâncias, algumas gerando aumento de pena, outras, diminuição. As elevações são obtidas por meio de qualificadoras e causas de aumento; as diminuições, por meio de privilégios e causas de diminuição.

(...) A qualificadora, quando presente, altera a faixa de fixação abstrata da pena (no caso do furto, pode-se alterá-la para dois a oito anos e multa conforme §4º - ou para três a oito conforme §5º), somente se pode eleger uma faixa para a pena, logo, escolhe-se a mais grave: de três a oito anos. A circunstância remanescente, pertencente à outra qualificadora do §4º (por exemplo, rompimento de obstáculo), deve ser levada em conta na aplicação da pena-base, como circunstância judicial. Entretanto, a incidência concomitante de causas de aumento e de diminuição, previstas no mesmo tipo penal, podem (e devem) ser aplicadas umas sobre as outras. Por isso, se houver furto noturno, cometido por primário, com coisa de pouco valor, pode-se fazer incidir o §§1º e 2º. Diante disso, presente apenas uma circunstância qualificadora do §4º (ilustrando, a escalada), além da causa de aumento de ter sido o crime cometido durante o repouso noturno, prevista no §1º, nada impede a aplicação de ambas. O juiz parte da faixa indicada pelo §4º, por conta da escalada, logo, dois a oito anos; fixa a pena-base, com fruto no art. 59 do CP; verifica se há agravantes ou atenuantes (arts. 61 a 65); finalmente, insere as causas de aumento, no caso, um terço a mais, por consideração ao §1º. (...) A posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena. Outras considerações, para não aplicar o aumento do §1º às formas qualificadas (§4º ou §5º, constituem pura política criminal, visando à menor apenação ao acusado, embora distante da técnica de individualização da pena".

Segundo o entendimento da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, não existe incompatibilidade entre a causa de aumento especial prevista no §1º e as qualificadoras do §4º, ambas do artigo 155 do Código Penal.

Não incide o princípio da insignificância, na espécie.

No caso em tela, não estão presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, da nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ora, a conduta, tal como revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal, tratando-se de furto praticado de forma premeditada e audaciosa, durante o repouso noturno, por indivíduo que se dedica à prática de crimes patrimoniais, revelando, o comportamento do acusado, significativo grau de reprovabilidade (neste sentido: TJSP Apelação nº 0010441-04.2010.8.26.0224. Rel.

Des. Souza Nery. 9ª Câ. Dir. Crim. Julgada em 12.12.2013 e STJ HC 192351 MG 2010/0224317-6, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, Julgamento de 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

Não preenchidos os predicados legais, afasta-se a benesse do furto privilegiado. O acusado é reincidente e ostenta antecedentes criminais.

Finalmente, não se olvida a justificativa ofertada pelo réu para a prática do delito: O acusado aduziu que estava sob efeito de droga e pretendia trocar os objetos que subtrairia do interior do carro da vítima por crack.

Ainda que adotada como verdadeira a premissa defensiva, por si só, não é suficiente para o afastamento de sua culpabilidade.

Em Juízo, o acusado não apresentou indicativo que revelasse estar sua capacidade cognitiva comprometida em razão do uso de substância entorpecente. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura.

O réu declarou, ainda, que preso há pouco mais de três meses, 'passa bem'. Não relatou alteração comportamental ou de saúde, quadro que não se coaduna com o de um dependente químico. Outrossim, não foi requerida a instauração de incidente de dependência químico-toxicológica pela defesa e este Juízo não vislumbrou elementos para a determinação da diligência de ofício.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Dessarte, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado, que ostenta condenação anterior e irrecorrível por tráfico de droga (autos nº 0050162-15.2007.8.26.0564, da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 21/10/2011. Pena extinta em 22/06/2015, cf. certidão de distribuição criminal de págs. 48/50 e F.A de págs. 51/61).

As desfavoráveis condições subjetivas do acusado não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena. Elevo a pena-base em 1/6, o que perfaz 02 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

A seguir, verifica-se a agravante da reincidência (autos nº 0034218-26.2014, que tramitaram na 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2016. Identificada na F.A como execução nº 03, consta no documento cumprimento da pena privativa de liberdade em 2021) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, 'd'), operando-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil).

A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: "A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no

REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento do repouso noturno (CP, art.155, §1º). Elevo a pena em 1/3, o que perfaz 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Reconhecida a tentativa, pondero que o acusado foi surpreendido no início da execução criminosa. Estilhaçou o vidro da uma das janelas e, de pronto, enquanto buscava concluir o rompimento do obstáculo diante da dificuldade imposta pela instalação de insulfilm, foi surpreendido pela vítima, circunstância que o obrigou a deixar o local. Considerando o iter criminis percorrido, reduzo a reprimenda no patamar máximo de 2/3, o que perfaz 01 ano e 13 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica do acusado, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado.

É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada as desfavoráveis condições subjetivas do acusado, que bem demonstram a sua ousadia e periculosidade diferenciada, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpra salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática REITERADA de crimes pelo réu, que deles fez o seu meio de vida, denota conduta social inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade mais severa.

O acusado ostenta diversas condenações irrecorríveis por delitos de tráfico de droga e de roubo.

É reincidente.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, para permitir ao Juiz que descontasse na sentença o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade da conduta do agente, diante de suas desfavoráveis condições subjetivas, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP 5ª Câmara Criminal – Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o

NIVALDO SOUSA DE LIMA, qualificado nos autos às págs.24/27 e 45, como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 04 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O acusado respondeu preso ao processo, convertida a prisão em flagrante em preventiva (págs. 74/76).

Mantenho a prisão preventiva do acusado, pois presentes seus requisitos.

Na hipótese vertente, o fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, no depoimento do policial militar, na confissão judicial do acusado e na presente condenação.

O periculum libertatis vê-se configurado nas desfavoráveis condições subjetivas do acusado, que se dedica à prática ininterrupta de crimes e é reincidente. O delito apurado nestes autos não configura mero desvio na vida do acusado, que demonstra periculosidade diferenciada. Há fortes indícios de que, em liberdade, reiterará a conduta. Mister garantir a ordem pública.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, pois não suficientes e adequadas à espécie, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do acusado para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos da prisão preventiva, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

De plano, autorizo a destruição do alicate apreendido às págs. 14/15. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, arts.393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, art.398, após o trânsito em julgado).

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA